

1501160-75.2020.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

"ENTORPECENTE - Tráfico Desclassificação para o uso próprio Admissibilidade Elevada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501160-75.2020.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501160-75.2020.8.26.0457

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256868/2020 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 14167608 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 1715/20/814 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2256868 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSÉ LUIS RODRIGUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

JOSÉ LUIS RODRIGUES JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, porque no dia 16/10/2020, por volta de 06h30min, nesta cidade, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia de 25/11/2020 (fls. 113/116) que, segundo o apurado, no bojo da "Operação Ostentação", equipe formada por policiais civis se dirigiu à casa dos denunciados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 1501121-78.2020.8.26.0457, desta 3ª Vara Criminal (cf. fls. 21/22), expedido em desfavor do ora réu. A equipe foi recebida por ele e por sua companheira e, dando cumprimento à ordem judicial, foram iniciadas buscas pela residência do denunciado.

No interior de um armário localizado no banheiro da casa, foi localizada uma porção de 21,2 gramas de "maconha". Na cozinha, dentro do fogão, homiziada sob as chapas do forno, foi encontrada uma porção de "cocaína", que perfazia 36,5 gramas do entorpecente. No quarto do casal, dentro do guarda roupas, os policiais encontraram a quantia de R\$1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais) em espécie, em notas de diversos valores, guardada dentro de uma pequena bolsa, cuja origem lícita não foi demonstrada. No chão do aposento, foi encontrada uma maquineta de cartões. Por fim, no interior do carro do réu, os policiais encontraram dois recibos de depósitos bancários, nos valores de R\$1.000,00 (mil reais) e R\$11.000,00 (onze mil reais), tendo como beneficiárias Giovana Coriolano Soares e Brunna Costa Franco, sendo que a destinação das quantias não restou bem esclarecida (fl. 20).

Em solo policial, o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes, conquanto tenha alegado que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Notificado o réu (fls. 146), foi recebida a denúncia em 11/01/2022 (fls.155).

Audiência designada para 16/03/2022, na qual foram ouvidas duas testemunhas da acusação, tendo sido, então, designada audiência em continuação para 10/05/2022 (fls. 168).

Nesta, o réu foi interrogado (fls. 173). Em debates orais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto o Dr. Defensor pugnou pela desclassificação para o delito de uso próprio, requerendo ainda a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação (fls. 11) e laudos periciais (fls. 91/93 e 94/96).

Embora a autoria seja também certa e inconteste, penso que não resta suficientemente provada a destinação de traficância do entorpecente apreendido, em especial pela prova oral produzida.

Em juízo, a testemunha Tiago, policial civil, disse ter participado do cumprimento do mandado de busca; disse que o próprio acusado indicou alguns locais onde estavam guardados entorpecentes; disse ter sido localizado, também, uma maquineta de cartão, dinheiro em espécie e balança; o réu disse, na ocasião, que a droga era para consumo próprio, não tendo oferecido justificativa para o dinheiro em espécie.

A testemunha Alan, policial militar que também acompanhou o cumprimento do mandado de busca, asseverou ter participado da "Operação Ostentação", porém, não atuou diretamente na busca realizada na residência do réu; disse ser o réu conhecido dos meios policiais de abordagens e suspeitas anteriores, porém nada de ilícito jamais foi localizado ou provado em seu desfavor; disse ser o réu sobrinho de André "Coringa", traficante bastante conhecido nos meios policiais; disse que havia suspeitas e investigações de que o réu utilizava um veículo VW Gol para a movimentação de drogas, tendo sido constatado em uma oportunidade, inclusive, que tal veículo tinha as placas adulteradas com algo semelhante à fita isolante, o que foi verificado na própria residência do réu, que não possui muros ou portão frontal.

O réu, por sua vez, em juízo, admitiu a posse das drogas, aduzindo ser dependente químico há muito tempo; com relação ao dinheiro, disse ser de sua esposa, que

trabalha como cabeleireira; sobre a balança de precisão, sustentou que também é utilizada por sua esposa para “pesar cabelo” na realização de procedimentos de aplique ou mega hair; afirmou já ter sido internado, no passado, por dependência química; sobre André “Coringa”, disse ser seu tio, porém não possuem relação de proximidade, sendo que o encontrava esporadicamente junto a familiares, principalmente quando ia até a casa de seu pai, que morava aos fundos da residência de André; sobre o veículo, disse que a placa estava “descascada”, e por isso a numeração parecia ser outra.

Respeitado o posicionamento final do Ministério Público, não vislumbro elementos suficientes que comprovem, de maneira indene de dúvidas, que o réu pratique a mercancia da droga, sendo que nem mesmo a quantidade de droga apreendida, milita nesse sentido.

Como disse a própria testemunha Alan, policial militar, ele próprio abordou o réu em ao menos quatro oportunidades distintas e, em todas elas, nada de ilícito foi localizado.

Não foi pleiteada e tampouco realizada perícia no veículo que supostamente seria destinado ao transporte de drogas; não há segurança sequer da ventilada adulteração da placa.

O réu, por sua vez, fez prova, ao menos indiciária, da licitude do dinheiro encontrado em sua residência. Sua esposa realmente é cabeleireira (fls. 48), havendo várias fotografias que comprovam a existência do salão de beleza (fls. 49/57), o que por certo justifica a movimentação de dinheiro em espécie, principalmente em quantias não muito elevadas, como é o caso dos autos.

A balança, por sua vez, realmente parece ser objeto comum para profissionais que realizam apliques (mega hair), eis que costumeiramente a cobrança pelos apliques envolve o tamanho ou o peso do cabelo. Há até mesmo fotografias de cabelos sendo pesados (fls. 58/59).

Destaco, ademais, que o réu é primário (fls. 123/124), não havendo dados concretos de seu envolvimento com o tráfico – somente seu parentesco com André “Coringa”, o que, por si só, não é prova apta a embasar um édito condenatório.

Assim, tenho que as provas coligidas aos autos realmente são bastante circunstanciais, deixando cenário de bastante dúvida quanto à tese acusatória de traficância.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“ENTORPECENTE - Tráfico Desclassificação para o uso próprio Admissibilidade Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando aplicação do princípio in dubio pro reo” - RT 841/520.

“ENTORPECENTE Tráfico Desclassificação para o uso próprio Admissibilidade Pequena quantidade de droga apreendida Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal Inteligência do art.16 da Lei 6368/76” RT 842/527.

Desta forma, restou apenas a certeza de que o increpado estava com drogas, mas como

dito acima em pequena quantidade e, de forma isolada, sem aptidão para configurar o delito imputado. Importante lembrar que em direito penal, em caso de dúvida, ela deve ser resolvida em favor do acusado.

Para o decreto condenatório não bastam os indícios da autoria e prova da materialidade, mas tem que haver a certeza de que o réu praticou (seja como autor, coautor ou partícipe) o fato criminoso.

Por esse motivo a Lei Processual Penal prevê que as provas colhidas durante o Inquérito policial devem ser corroboradas pelas produzidas em juízo, caso contrário, não poderá haver condenação com fundamento exclusivo em elementos informativos colhidos em investigação (artigo 155, caput, segunda parte).

O aludido texto legal é complementado pelo artigo 386, incisos V e VII, o qual dispõe sobre a impossibilidade de condenação caso não haja prova suficiente da autoria, consoante o princípio *in dubio pro reo*.

Assim, na dúvida, a garantia da liberdade deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Nossa jurisprudência já decidiu que:

“Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (RT 708/339).

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do réu se impõe” (RJTJSP 10/545).

E, in casu, não há certeza da autoria.

Desse modo, à luz da prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, não há mesmo como se afirmar, com segurança, que o réu José Luis tenha concorrido para a suposta infração penal narrada na denúncia, impondo-se a absolvição.

A rigor, seria o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Todavia, com relação ao delito acima indicado, teço algumas considerações.

Muitas são as polêmicas acerca do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, tantas que a Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em Acórdão da lavra do Desembargador JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES, considerou-o inconstitucional. Confira-se:

O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (TJSP – Apelação Criminal nº 01113563.3/0-0000-000, 6ª Câmara Dir. Criminal, j. 31/03/2008).

Da brilhante fundamentação do v. Acórdão extrai-se:

Assim, transformar aquele que tem a droga apenas e tão-somente para uso próprio em agente causador de perigo à incolumidade pública, como se fosse um potencial traficante, implica frontal violação do princípio da ofensividade, dogma garantista previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, a criminalização do porte para uso próprio também viola o princípio constitucional da igualdade, pois há flagrante "distinção de tratamento penal (drogas ilícitas) e não-penal (drogas lícitas) para usuários de diferentes substâncias, tendo ambas potencialidade de determinar dependência física e psíquica" (Salo de Carvalho, A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático, Editora Lumen Juris, RJ, 2007, p. 253).

Data máxima vênia à Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, não me animo, confesso, a uma decisão de tamanha envergadura. Creio que é suficiente para resolver a questão, por outro prisma, a aferição da periculosidade ou ofensividade da conduta e seu desvalor social. Como inúmeras vezes já enfatizei, estou convicto acerca da ausência de lesividade da conduta em casos tais, pois, segundo me parece, a conduta do consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica.

Destaco à luz do princípio da insignificância os seguintes julgados:

"Entorpecente. Quantidade ínfima. Atipicidade. O crime, além da conduta, reclama um resultado no sentido de causar dano ou perigo ao bem jurídico (...); a quantidade ínfima informada na denúncia não projeta o perigo reclamado". 1 Sempre "é importante demonstrar-se que a substância tinha a possibilidade para afetar ao bem jurídico tutelado". A pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Quando a conduta não seja reprovável, sempre e quando a pena não seja necessária, o juiz pode deixar de aplicar dita pena. O Direito penal moderno não é um puro raciocínio de lógica formal. É necessário considerar o sentido humanístico da norma jurídica. Toda lei tem um sentido teleológico. A pena conta com utilidade" (decisão de 21.04.1998, relator LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU de 17.08.1998, p. 96.).

"Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal).

Não bastasse a circunstância da ínfima quantidade do estupefaciente, a tornar atípica a conduta, como acima visto, penso, sobretudo tendo em vista a despenalização da figura típica, conforme o art. 28 da Lei 11.343/06, que a conduta do consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica. Destaco a propósito o voto do Desembargador Nereu José Giacomolli, que ainda ao tempo do art. 16 da Lei 6368/76, bem enfocou a questão:

"O princípio da ofensividade ao bem jurídico, como afirma Luiz Flávio Gomes (Princípio da Ofensividade no Direito Penal, p. 25), há de ser instrumentalizado e tornado efetivo, sob pena de se ter um discurso liberal e uma aplicação autoritária do Direito Penal. Como bem ensina Carbonell Mateu (Derecho Penal: Concepto y Principios Constitucionales, 1999, p. 215-218), o princípio da ofensividade ou lesividade exige que não haja crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, dentro de um critério valorativo que a norma comporta. Mais, num Estado Social e Democrático de Direito, a intervenção punitiva somente se justifica nas condutas transcendentais aos demais que atinjam as esferas de liberdade alheias, sendo contrário ao princípio da ofensividade o castigo de uma conduta imoral, antiética

ou antiestética que não invada a liberdade alheia. Ainda, este princípio descansa na consideração do crime como um ato desvalorado, isto é, contrário à norma de valoração" (TJRS - RJTJRGS 240/74 - Rec. 70013554571 - j. 18.05.2006 - RJTJRGS 257/197 e Ap. 70008849051 - j. 26.08.2004).

Penso prudente enfatizar que já ao tempo da lei 6368/76 havia outros entendimentos jurisprudenciais no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que consideravam atípica a conduta do porte de entorpecente:

"O legislador sanciona a aquisição, a guarda e o porte do entorpecente para uso próprio, entendendo que 'o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo porque é fator decisivo na difusão do tóxico. No entanto, a partir do momento em que a consome, lesa a si próprio e sua conduta não representa mais um perigo social' (Ap. 168.697, TACRIM). Falta lesividade e sem ela não atua o Direito Penal, pois, na lúcida observação de Claus Roxin, 'o legislador, mandatário do povo, tem sua tarefa limitada à proteção do indivíduo dos ataques dos outros e a assegurar uma vida mais livre possível e de maior bem-estar possível, e nada tem a ver com tal tarefa o tutelar moralmente cidadãos adultos contra sua vontade' (Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Trad. cast. Barcelona, 1989, p. 22)" (TJSP - Ap. - Rel. Dante Busana - JTJ 168/321).

Não bastassem tais considerações sobre a figura típica do porte do entorpecente e a autolesividade, ainda acerca do princípio da insignificância poderiam ser lembrados os seguintes julgados:

"O fato penal apurado neste processo, por sua irrelevância e escassa gravidade, não deveria ter merecido significação penal, porque não ameaçou e nem ofendeu substancialmente o bem jurídico tutelado pela lei penal. É claro que, formalmente, a conduta executada pelo sujeito ativo preencheu os elementos compositivos da norma incriminadora, o que bastaria para configurar o crime, considerado o seu conceito formal. Contudo, a ação não lesionou nem ameaçou o bem jurídico resguardado pela lei de forma que justificasse a necessidade de se invocar a proteção penal, situação que pode determinar o reconhecimento da improcedência da denúncia, nos termos da regra do art. 386, III, do CPP (atipicidade do comportamento realizado). Sob o conceito material, 'crime é um desvalor da vida social, ou seja, uma ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com uma pena, porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem, ou a um valor da vida social' (Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, 13.^a ed., 1991, p. 144). Sob esse aspecto substancial ficou evidente que o comportamento não revelou ofensa ao bem jurídico protegido" (TA-CRIM-SP - Ap. 1031723-5 - Rel. Márcio Bártoli).

"A natureza fragmentária do direito penal impõe que ele só se ocupe da proteção do bem jurídico relevante e não de bagatelas, sendo causa de exclusão da tipicidade a insignificância da conduta" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Márcio Bártoli - j. 05.02.97 - RJDTCrim 35/491).

Penso oportuno destacar que o princípio da insignificância deve ser aplicado também a réus eventualmente reincidentes, ou que tenham sido condenados em sentença pendente de recurso, visto que para o acolhimento daquele princípio tem-se em conta o ínfimo desvalor social da conduta, e não propriamente as condições pessoais do sujeito ativo da infração. Vale recordar o seguinte v. aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

INSIGNIFICÂNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível à distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor... 2. In casu, a res furtiva se enquadra no conceito de bagatela, pois a interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto no caso concreto. 3. Circunstâncias de

caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e maus antecedentes, não interferem no reconhecimento do princípio da insignificância (STJ - AgRg no REsp 922863 / RS - Ministra JANE SILVA - DJe 08/09/2008).

Discorrendo sobre o art. 28, Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini sustentam que "houve descriminalização formal (acabou o caráter criminoso do fato) e, ao mesmo tempo, despenalização (evitou-se a pena de prisão para o usuário de droga). O fato (posse de droga para consumo pessoal) deixou de ser crime (formalmente) porque já não é punido com reclusão ou detenção" (art. 1º da LICP) e concluem que se trata de uma "infração penal sui generis" (GO-MES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Usuário de drogas: a polêmica sobre a natureza jurídica do art. 28 da Lei 11.343/06. Disponível em: <http://www.lfg.blog.br>. 12 mar. 2007).

Sem desconhecer decisões em sentido contrário que – mais apegadas ao aspecto da incolumidade pública (supostamente violada com a conduta do porte de entorpecentes) – afastam a aplicação do princípio da insignificância a casos tais, penso, modestamente, que a inovação trazida pelo art. 28 da Lei 11343/06 é de tamanha amplitude e de tão evidente inocuidade que no meu despretenso entendimento acredito mais sensato simplesmente deixar de aplicar o novel diploma para não lançar descrédito sobre as normas penais.

Confesso não haver encontrado na pesquisa jurisprudencial um tanto aprofundada qualquer precedente que tratasse da questão a seguir ventilada, mas atrevo-me a ponderar que a "brandura" da punição é tamanha, com "resultado imponderável" – dizeres de Guilherme de Souza Nucci, in "Leis Penais e Processuais Comentadas", RT, 2ª, p. 304 – que no meu modesto entendimento a inovação legislativa pode conduzir a uma situação contraditória: se o suposto autor do fato aceitar a transação penal (Lei 9099/95) estará, nessa hipótese, obrigando-se a uma prestação pecuniária ou prestação de serviços, com a única vantagem de evitar possível reincidência em casos futuros em decorrência daquela decisão judicial; se, ao invés disso, o autor do fato recusar a transação penal e a pretensão acusatória for julgada procedente, as sanções previstas no art. 28 (se é que tais medidas constituem efetiva sanção) seriam tão brandas que poderiam tornar-se um estímulo a novos delitos da mesma natureza ou quiçá ainda mais graves.

Diante desse quadro, acredito que há um paradoxo, ainda não suficientemente enfocado pelos tribunais: do ponto de vista prático talvez seja mais vantajoso ao autor do fato ser condenado sem sanção efetiva alguma que aceitar uma transação penal. Daí porque, penso mais prudente deixar de aplicar a transação penal, tudo para que o direito penal não caia num verdadeiro ridículo.

A propósito penso conveniente ressaltar a observação de Ana Luiza Barbosa da Cunha sobre o tratamento dado pelo legislador à questão:

"Todavia, não podemos deixar de observar, por derradeiro, que, muitas vezes, o objetivo do legislador de ressocializar e reintegrar o consumidor de drogas ficará inócuo, principalmente em se tratando da aplicação do instituto despenalizador da transação penal. Isso porque o novo diploma legal traz um tratamento por demais branda em relação ao não cumprimento das penas, só podendo incidir advertência acerca da necessidade de cumprir a pena alternativa e podendo chegar à aplicação da multa, porém, é sabido dos aplicadores do direito a dificuldade em se promover uma execução em razão da necessidade de possuir patrimônio. "A nova lei de drogas e o tratamento processual dispensado ao usuário" (Disponível em: <http://www.blogdolfg.com.br>, 19.julho.2007).

Inobstante, é certo, ainda, que há Recurso Extraordinário em trâmite na Corte Constitucional sob número 635.659 cujo objeto é justamente a análise da (in)constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo que, lá, já há amplo debate sobre o tema, havendo voto favorável à declaração de inconstitucionalidade

dos Excelentíssimos Senhores Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luis Roberto Barroso.

Consta do voto do relator, até o momento acompanhado pelos pares, que a "criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional".

Aliás, peço venia para transcrever, embora extenso, pertinente trecho do voto do i. Ministro Edson Fachin:

(...) A interpretação do Direito Penal à luz da Carta da República tem sentido a partir de duas premissas básicas: a diferenciação entre penas e medidas de segurança, e a exigência de expressa previsão constitucional, para justificar a limitação de direitos fundamentais. A primeira premissa indica que, em situações excepcionabilíssimas, é possível atribuir a qualidade de perigo a determinada pessoa. Por isso, exceto nas situações em que o desenvolvimento bio-psico-social afaste a culpabilidade, a separação entre penas e medidas de segurança jamais autorizaria fazer recair sobre a pessoa do agente o juízo de condenações. Já neste ponto é possível antever que a incriminação da drogadição situa-se na tênue delimitação entre o Direito Penal do autor e o do fato. Com efeito, a posse para uso pessoal, embora tipifique a ação, incide sobre conduta que, não raro, é condição essencial da pessoa, e a vetor constitucional que não autoriza a penalização da personalidade. No que tange às limitações dos direitos fundamentais, é preciso que eventual restrição encontre fundamentação constitucional. Nessa diretriz, alberga-se o princípio da tipicidade, a exigir reserva de lei para normas penais. Considerando que a tipicidade decorre da teoria sobre os direitos fundamentais, ao legislador não compete apenas observar a reserva de lei para tipificar determinada conduta, como também deve demonstrar que pela incriminação outro direito fundamental será protegido. A doutrina costuma indicar que a sede do princípio da ofensividade como parâmetro de controle de constitucionalidade reside no art. 98, I, da Constituição da República. Embora a referência tópica possa constar desse dispositivo, o conteúdo do princípio decorre, de um lado, da opção constitucional e legal por um Direito Penal orientado por fatos; e, de outro, da impossibilidade de se criminalizar condutas que não atinjam um fundamento constitucionalmente assegurado. Nesse sentido, é correto afirmar que o princípio da ofensividade tem assento constitucional e serve de parâmetro para o controle da atividade do Legislativo. Esse controle não incide, entretanto, indistintamente sobre todas as normas penais, nem sobre os objetivos e motivações invocados para edição da norma, pois, em tais circunstâncias, seria preciso recorrer-se a argumentos consequencialistas, para afastar a prerrogativa de avaliação feita pelo Legislativo. O princípio da ofensividade permite, de fato, a limitação do próprio direito, mas não autoriza que se oponham argumentos utilitários à validade normativa. Essa tarefa tem ainda maior importância se o reconhecimento da extensão dos bens jurídicos e da consequente proteção estatal for medida em relação à eventual restrição da liberdade. Nesse sentido, caberia à teoria do bem jurídico identificar quais bens podem justificar a restrição à liberdade. Não se trata, contudo, de afastar a priori qualquer pretensão de permitir ao Estado perseguir fins morais. Ao contrário, inexistente um princípio que delimite a esse ponto a atividade estatal regulatória. É preciso registrar, neste particular, que a possibilidade de se buscar fins morais não é descontextualizada: apenas em sociedades em que haja o respeito à autonomia dos cidadãos, garantindo-se-lhes um amplo espectro de opções valorosas (RAZ, Joseph. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1986), é que seria possível falar em uma larga margem de avaliação para estabelecer fins morais. O ponto de partida para se delimitar o campo de restrição à autonomia parece estar no princípio da ofensividade: somente havendo dano efetivo, porquanto haveria, por conseguinte, uma interferência na autonomia das outras pessoas, é que se pode legitimar a coerção. A sanção penal é, assim,

tão-só uma das formas de se proteger os bens jurídicos. Consubstanciando a mais grave restrição na autonomia dos cidadãos, cumpre, portanto, avaliar se ela é adequadamente posta. E é aqui que tem assento a proporcionalidade. Especificamente em relação à coerção penal, poder-se-ia apontar, na linha do que indica Claus Roxin, serem ilegítimas as incriminações de: motivações ideológicas; autolesão; tabus; fins extrapenais; e abstrações incapazes de constituir bens jurídicos (ROXIN, Claus. Es la proteccion de los bienes jurídicos una finalidad del derecho penal? In: La teoría del bien jurídico. Fundamentos de legitimación del derecho penal o juego de laboratorios dogmáticos? Roland Hefendehl (ed.). Barcelona: Marcial Pons, 2007). Essas considerações parecem indicar que, em vista da ofensa a um bem individual, não se pode dar ensejo à criminalização. Esse norte tem sentido especialmente para o adicto, usuário dependente de droga; impende ajudar o usuário que queira se livrar do poder criminoso da dependência. Frise-se, relativamente a esta inferência, que não se visa inviabilizar a atividade regulatória do Estado, nem mesmo a de imposição de sanções, mas a afastar que a regulação seja feita por meio da coerção penal como primeiro antídoto. (...)

Já Gilmar Mendes, assim asseverou:

(...) Na valoração da importância de determinado interesse coletivo como justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do dano potencial associado à conduta objeto de incriminação. Em outras palavras, há que se verificar em que medida os riscos a que sujeitos os interesses coletivos podem justificar a conversão destes em objeto de proteção pelo direito penal. Conforme observa PUIG, o Estado Social não pode desconhecer, [na definição de crimes de perigo abstrato], a significação que, por si mesma, implica a extensão social de um determinado interesse e tampouco há de prescindir da exigência de um mínimo de repercussão do interesse coletivo em relação a cada indivíduo. Acredita o autor ser essa a via adequada se se pretende evitar a hipertrofia do direito penal (PUIG, Santiago Mir, "Concepto de Bien Jurídico-Penal como Limite del Ius Puniedi", Estudos de Direito Penal, Processual e Criminologia em Homenagem ao Prof. Dr. Kurt Maldlener, coordenadores Adhemar Ferreira Maciel et alli. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciário, 2014). E exemplifica justamente com o direito à saúde pública. Não cabe negar, afirma o autor, que a saúde pública é um interesse coletivo que afeta cada indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade individual para que se possa justificar a intervenção do direito penal. Até agora não se tem afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco afetam suficientemente a saúde pública a ponto de legitimar a criminalização de sua venda e consumo. Em relação ao tabaco, observa que a proteção da ordem pública coletiva tem sido alcançada com o incremento da proibição de seu consumo em lugares públicos, porém por meio de medidas administrativas. O mesmo raciocínio, ainda segundo PUIG, aplica-se em relação às drogas. Sustenta ser preciso diferenciar as drogas quanto a seus distintos efeitos em relação a cada indivíduo. Além disso, há que se ter em conta que a lesividade individual vem, neste caso, acompanhada do consentimento da vítima. Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas art. 4º da Lei 11.343/06 é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas. Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade. Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social. A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento

criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal. Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional. (...)

Ante o exposto, ressaltando que atípico, a meu ver, o fato (posse de drogas para consumo próprio), JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO o réu JOSÉ LUIS RODRIGUES JUNIOR, com fundamento no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Fica autorizada a destruição de eventuais amostras guardadas para contraprova, conforme art. 72 da Lei de Drogas, assim como a restituição ao investigado de eventuais bens apreendidos no inquérito policial.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

P.I.C.

Pirassununga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA